

Q208160

Ano: 2005 Banca: OAB-SP Órgão: OAB-SP Prova: OAB-SP - 2005 - OAB-SP - Exame de Ordem - 2 - Primeira Fase

Quando o administrador socorre-se de parâmetros normativos e se vale de procedimentos técnicos e jurídicos prescritos pela Constituição e pela lei, para balancear os interesses em jogo e tomar uma decisão que tenha mais legitimidade, diz-se que ele:

- () A) instituiu privilégio para atender ao princípio da supremacia do interesse público
- () B) aplicou a verticalidade das relações entre Estado e particular.
- () C) exerceu discricionariedade.
- () D) realizou uma competência vinculada.

5.8. Questões

Q829490

Ano: 2017 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2017 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XXIII - Primeira Fase

Ao realizar uma auditoria interna, certa entidade administrativa federal, no exercício da autotutela, verificou a existência de um ato administrativo portador de vício insanável, que produz efeitos favoráveis para a sociedade Tudo beleza S/A, a qual estava de boa-fé. O ato foi praticado em 10 de fevereiro de 2012. Em razão disso, em 17 de setembro de 2016, a entidade instaurou processo administrativo, que, após o exercício da ampla defesa e do contraditório, culminou na anulação do ato em 05 de junho de 2017.

Com relação ao transcurso do tempo na mencionada situação hipotética, assinale a afirmativa correta.

- * () A) Não há decadência do direito de anular o ato eivado de vício, considerando que o processo que resultou na invalidação foi instaurado dentro do prazo de 5 (cinco) anos.
- () B) Consumou-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública federal.
- () C) O transcurso do tempo não surte efeitos no caso em questão, considerando que a Administração pode anular seus atos viciados a qualquer tempo.
- () D) Consumou-se a decadência para o exercício da autotutela, pois, entre a prática do ato e a anulação, transcorreram mais de 5 (cinco) anos.

Q349734

Ano: 2013 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2013 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XII - Primeira Fase

O Estado X concedeu a Fulano autorização para a prática de determinada atividade. Posteriormente, é editada lei vedando a realização daquela atividade. Diante do exposto, e considerando as formas de extinção dos atos administrativos, assinale a afirmativa correta.

- () A) Deve ser declarada a nulidade do ato em questão.
- * () B) Deve ser declarada a caducidade do ato em questão.
- () C) O ato em questão deve ser cassado.
- () D) O ato em questão deve ser revogado.

Q261973

Ano: 2012 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2012 - OAB - Exame de Ordem Unificado - VII - Primeira Fase

Acerca das modalidades de extinção dos atos administrativos, assinale a alternativa correta.

- () A) A renúncia configura modalidade de extinção por meio da qual são extintos os efeitos do ato por motivo de interesse público.
- () B) A cassação configura modalidade de extinção em que a retirada do ato decorre de razões de oportunidade e conveniência.
- () C) A revogação configura modalidade de extinção que ocorre quando a retirada do ato se dá por ter sido praticado em contrariedade com a lei.
- *() D) A caducidade configura modalidade de extinção em que ocorre a retirada do ato por ter sobrevivido norma jurídica que tornou inadmissível situação antes permitida pelo direito e outorgada pelo ato precedente.

Q213692

Ano: 2011 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2011 - OAB - Exame de Ordem Unificado - V - Primeira Fase

A revogação representa uma das formas de extinção de um ato administrativo. Quanto a esse instituto, é correto afirmar que:

- () A) pode se dar tanto em relação a atos viciados de ilegalidade ou não, desde que praticados dentro de uma competência discricionária.
- () B) produz efeitos retroativos, retirando o ato do mundo, de forma a nunca ter existido.
- *() C) apenas pode se dar em relação aos atos válidos, praticados dentro de uma competência discricionária, produzindo efeitos *ex nunc*.
- () D) pode se dar em relação aos atos vinculados ou discricionários, produzindo ora efeito *ex tunc*, ora efeito *ex nunc*.

Q171061

Ano: 2010 Banca: CESPE Órgão: OAB Prova: CESPE - 2010 - OAB - Exame de Ordem - 3 - Primeira Fase

Acerca das modalidades de extinção dos atos administrativos, assinale a opção correta.

- () A) A cassação configura modalidade de extinção em que a retirada decorre de razões de oportunidade e de conveniência.
- *() B) A caducidade configura modalidade de extinção em que ocorre a retirada por ter sobrevivido norma jurídica que tornou inadmissível situação antes permitida pelo direito e outorgada pelo ato precedente.
- () C) A revogação configura modalidade de extinção cuja retirada ocorre por motivos de conveniência, oportunidade e ilegalidade.
- () D) A renúncia é modalidade de extinção por meio da qual são extintos os efeitos do ato por motivos de interesse público.

Q156926

Ano: 2010 Banca: CESPE Órgão: OAB Prova: CESPE - 2010 - OAB - Exame de Ordem Unificado - I - Primeira Fase

Assinale a opção correta no que se refere à revogação dos atos administrativos.

- () A) A revogação do ato administrativo produz efeitos *ex tunc*.
- *() B) Atos vinculados não podem ser objeto de revogação.
- () C) A revogação pode atingir certidões e atestados.
- () D) Atos que gerarem direitos adquiridos poderão ser revogados.

Q197082

Ano: 2008 Banca: CESPE Órgão: OAB Prova: CESPE - 2008 - OAB - Exame de Ordem - 2 - Primeira Fase

Assinale a opção incorreta no que se refere à revogação de atos administrativos.

- () A) Os atos discricionários são, via de regra, suscetíveis de revogação.
- *() B) Os atos que exauriram seus efeitos podem ser revogados, desde que motivadamente.

- () C) Ao Poder Judiciário é vedado revogar atos administrativos emanados do Poder Executivo.
- () D) Os atos que geram direitos adquiridos não podem ser revogados.

Q299775

Ano: 2007 Banca: CESPE Órgão: OAB Prova: CESPE - 2007 - OAB - Exame de Ordem - 1 - Primeira Fase

Em relação ao controle da administração pública, assinale a opção correta.

- () A) Um ato administrativo que viole a lei deve ser revogado pela própria administração, independentemente de provocação.
- () B) A anulação do ato administrativo importa em análise dos critérios de conveniência e oportunidade.
- *() C) Um ato nulo pode, eventualmente, deixar de ser anulado em atenção ao princípio da segurança jurídica.
- () D) A administração tem o prazo prescricional de 5 anos para anular os seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade.

Q299416

Ano: 2007 Banca: CESPE Órgão: OAB Prova: CESPE - 2007 - OAB - Exame de Ordem - 2 - Primeira Fase

Em relação aos atos administrativos, assinale a opção correta.

- *() A) Revogação consiste na supressão de ato legítimo e eficaz realizada pela administração, por considerá-lo inconveniente ao interesse público.
- () B) A anulação de um ato administrativo, em regra, implica o dever da administração de indenizar o administrado pelos prejuízos decorrentes da invalidação do ato.
- () C) Os atos de gestão são os que a administração pratica no exercício do seu poder supremo sobre os particulares.
- () D) A presunção de legitimidade é atributo apenas dos atos administrativos vinculados.

Q208750

Ano: 2006 Banca: ND Órgão: OAB-DF Prova: ND - 2006 - OAB-DF - Exame de Ordem - 3 - Primeira Fase

O Secretário de Finanças do Distrito Federal resolve retirar da ordem jurídica um ato administrativo normativo que, depois de 2 (dois) anos de sua adoção, revela-se inconveniente. Assim, para eliminar a produção de efeitos futuros do ato, resguardados os efeitos lícitos produzidos durante os 2 (dois) anos referidos, a mencionada autoridade pública deve:

- () A) anular o ato;
- *() B) revogar o ato;
- () C) convalidar o ato;
- () D) autuar o ato.

PODERES ADMINISTRATIVOS

1. CONCEITO E ESPÉCIES
2. PODER VINCULADO
3. PODER DISCRICIONÁRIO
4. PODER HIERÁRQUICO
 - 4.1. Faculdades Decorrentes do Poder Hierárquico
5. PODER DISCIPLINAR
6. PODER DE POLÍCIA (POLÍCIA ADMINISTRATIVA)
 - 6.1. Fases do Poder de Polícia
 - 6.2. Delegação do Poder de Polícia
 - 6.3. Atributos do Poder de Polícia
7. PODER NORMATIVO ou REGULAMENTAR
8. ABUSO DE PODER
9. QUESTÕES

1. CONCEITO E ESPÉCIES

a) Conceito: poderes administrativos são prerrogativas concedidas pelo ordenamento jurídico à Administração Pública (Poder Executivo) para a consecução dos fins públicos: são decorrência direta da supremacia do interesse público.

Tratam-se dos poderes que a Administração Pública possui quando ela estiver desempenhando a função administrativa, que é preponderantemente realizada pelo Poder Executivo.

b) Espécies: há seis espécies de poderes administrativos:

- *Poder vinculado;*
- *Poder discricionário;*
- *Poder hierárquico;*
- *Poder disciplinar;*
- *Poder de polícia; e*
- *Poder normativo ou regulamentar.*

2. PODER VINCULADO

a) Conceito: Poder vinculado é o poder de que dispõe a Administração Pública para praticar atos administrativos vinculados, os quais – conforme já visto no material sobre “Atos Administrativos” – são a manifestação de vontade do Estado que ocorre sem qualquer margem de escolha para o administrador público: a norma jurídica estabelece o único comportamento possível a ser adotado pela Administração diante de determinada situação de fato.

b) Ausência de margem de escolha: portanto, no poder vinculado não há margem de liberdade ao administrador público; não há mérito administrativo, vale dizer, não há oportunidade (momento adequado) nem conveniência (interesse público).

O administrador público não pode fazer mais nem menos, pois o único ato possível é aquele que consta da lei.

Ex1: a aposentadoria possui vários requisitos dispostos na lei, como idade mínima, tempo de contribuição, carência... Se todos os requisitos foram atendidos pelo segurado, a Administração Pública (INSS: autarquia do Poder Executivo da União) é obrigada a conceder a aposentadoria.

Ou seja, preenchidos os requisitos legais, a Administração não pode deixar de conceder a aposentadoria por entender, por exemplo, que não é conveniente nem oportuno (isso é discricionariedade, que não está presente no poder vinculado) pelo fato de o segurado ainda ter disposição física e mental para trabalhar, porque as contas do INSS estão negativas ou por qualquer outra razão.

Ex2: na licença para construir também – trata-se de ato vinculado e, atendidos os requisitos previstos na legislação, o Poder Público deve obrigatoriamente deferir a licença para o cidadão requerente.

3. PODER DISCRICIONÁRIO

a) Conceito: poder discricionário é o poder de que dispõe a Administração Pública para praticar atos administrativos discricionários, nos quais – conforme também já foi visto no material sobre “Atos Administrativos” – o administrador público possui uma margem de escolha, possui certa liberdade de atuação.

b) Margem de escolha: a margem de escolha pode apresentar-se de vários modos diferentes: há situações em que a norma dará a opção ao Administrador Público (Poder Executivo) para praticar ou não o ato administrativo ou escolher entre limites mínimo e máximo:

- Praticar ou não o ato: aqui o Poder Executivo tem liberdade para praticar o ato administrativo ou não – cabe à Administração Pública decidir se o momento é adequado (oportunidade) e se há interesse público (conveniência) para a prática do ato administrativo.

- Limites: também há situações em que a norma jurídica determina que o ato administrativo seja praticado, mas dá ao Administrador Público a possibilidade de escolher entre limites mínimo e máximo (margem de escolha) dentro dos quais ele poderá atuar no caso concreto.

→ Discricionariedade X Arbitrariedade: relembre-se que ato discricionário não é sinônimo de ato arbitrário, pois o administrador não pode praticar o ato como “bem entender”; deve respeitar os limites “mínimo e máximo” fixados pela lei.

Quando houver margem de escolha e os limites legais forem respeitados, a Administração Pública estará praticando ato administrativo discricionário; mas quando extrapolar os limites impostos pela norma jurídica, estaremos diante de ato arbitrário, que é sinônimo de abuso de poder, que pode ser na modalidade excesso de poder (excesso de competência) ou desvio de poder (desvio de finalidade).

Ex.: um fiscal da vigilância sanitária, ao examinar a cozinha de um restaurante, verifica que está tudo em ordem; mas num cantinho da cozinha há alguns restos de alimentos estragados que estão separados para serem colocados na lixeira. Numa situação dessas, apesar de os alimentos estragados não poderem ficar ali, seria desarrazoado o fiscal determinar a interdição do restaurante; o mais prudente é que o fiscal, utilizando critérios de oportunidade e conveniência (discricionariedade), aplique uma advertência e determine que o responsável corrija esse problema e que evite sua repetição.

“Discricionariedade não é adotar atitudes extremas em relação a situações miseráveis.”

4. PODER HIERÁRQUICO

a) Conceito: o poder hierárquico está relacionado à organização administrativa.

É o poder de que a Administração Pública dispõe para:

- distribuir e escalonar funções; e
- ordenar e rever a atuação de seus agentes.

b) Interno: o poder hierárquico é um poder interno da Administração Pública, que ocorre no âmbito da sua organização administrativa, na relação entre órgãos públicos e entre chefia e subordinados.

O poder hierárquico é um poder que não se irradia externamente e, portanto, ele não atinge os particulares (o poder que atinge os particulares é o poder de polícia: veremos adiante).

c) Poder hierárquico ≠ Poder disciplinar: os poderes hierárquico e disciplinar são correlatos, mas não podem ser confundidos:

- *Poder hierárquico (organizar):* o poder hierárquico, que estamos estudando agora, diz respeito à organização da Administração Pública; e

- *Poder disciplinar (punir):* o poder disciplinar, que veremos abaixo, diz respeito ao poder de punição de que dispõe o Poder Público (Poder Executivo).

d) Hierarquia ≠ Vinculação: como já vimos no material sobre "Organização Administrativa", não podemos confundir hierarquia e vinculação;

- *Hierarquia (poder hierárquico) = subordinação = desconcentração (órgãos) = mesma PJ:* o poder hierárquico decorre do escalonamento vertical de órgãos ou agentes da mesma pessoa jurídica da Administração Pública, de modo que órgãos e agentes públicos de hierarquia superior exercem controle sobre os atos praticados pelos órgãos e agentes públicos de hierarquia inferior – os de hierarquia inferior são subordinados aos de hierarquia superior.

Na desconcentração administrativa, que é a criação de novos órgãos dentro de uma mesma pessoa jurídica, sempre teremos controle hierárquico.

- *Vinculação = controle finalístico = tutela administrativa = supervisão ministerial = ausência de subordinação = descentralização (entidades) = outra PJ:* já na vinculação temos o controle que é exercido pela administração direta (U+E+DF+M) sobre as pessoas jurídicas integrantes da sua administração indireta (A+FP+EP+SEM).

Portanto, as entidades da administração indireta são meramente vinculadas (não subordinadas) à administração direta que as criou.

Na descentralização administrativa, que é quando os Entes da administração direta (U+E+DF+M) criam entidades da administração indireta (A+FP+EP+SEM), o controle será meramente finalístico, por vinculação – não há hierarquia, não há subordinação.

4.1. Faculdades Decorrentes do Poder Hierárquico

O poder hierárquico gera algumas faculdades para a Administração Pública, quais sejam:

- *Dar ordens;*
- *Fiscalizar;*
- *Controlar (autotutela);*
- *Delegar competência; e*
- *Avocar competência.*

a) Dar ordens: a Administração Pública pode dar ordens a seus agentes públicos.

As determinações superiores (chefia) devem ser fielmente cumpridas pelos servidores subordinados, sob pena de infração administrativa.

- *Exceção (ordem manifestamente ilegal):* as ordens manifestamente ilegais não precisam ser cumpridas pelo subordinado (art. 116, IV, Lei Federal n.º 8.112/1990).

Ex.: a chefia pede para um subordinado agredir fisicamente um colega ou para ele praticar corrupção; essas ordens, obviamente, não precisam ser cumpridas porque são manifestamente ilegais.

Lei Federal n.º 8.112/1990

Art. 116. São deveres do servidor:

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

b) Fiscalizar: como decorrência do poder hierárquico, a Administração Pública também possui o poder fiscalizar seus órgãos e agentes públicos.

A fiscalização é realizada observando-se a hierarquia administrativa: os que estão acima fiscalizam aqueles que estão abaixo na hierarquia.

Cuidado:

- *Punir servidores (poder disciplinar):* o Poder Público obviamente também pode punir seus servidores; entretanto, a punição é uma decorrência do poder disciplinar (abaixo) e não do poder hierárquico (que estamos vendo agora);

- *Fiscalizar particulares sem vínculo (poder de polícia):* a Administração Pública também fiscaliza os particulares; mas nesse caso estaremos diante do poder de polícia (abaixo) e não do poder hierárquico.

c) Controlar (autotutela): do poder hierárquico também decorre a possibilidade de o Poder Público controlar os atos praticados por seus agentes públicos, ou seja, a Administração controlará seus próprios atos administrativos, pois os agentes públicos agem em seu nome. Disso decorrem as seguintes consequências (arts. 53-55 da Lei Federal n.º 9.784/1999):

- Manter: a Administração, ao analisar um ato administrativo praticado e verificando que o mesmo é válido, pode mantê-lo se ele ainda se revelar oportuno e conveniente.

- Convalidar: se o ato administrativo analisado apresentar um defeito sanável (passível de correção), a Administração pode convalidá-lo (corrigir o ato).

- Revogar (*mérito* = *revogar* = "*ex nunc*"): se o ato analisado é válido, ou seja, está com consonância com a lei (é um ato legal), mas ele se revela inoportuno ou inconveniente (*mérito*), a Administração pode revogá-lo, o que ocorrerá com efeito *ex nunc* (prospectivo, para a frente, dali em diante).

- Anular (*ilegal* = *anular* = "*ex tunc*"): por fim, se a Administração verificar que o ato administrativo analisado é ilegal, possui o dever de anulá-lo, o que terá efeito *ex tunc* (retroativo, desde a sua prática).

Lei Federal n.º 9.784/1999

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.

d) Delegar competência: o poder hierárquico também permite que haja a delegação do exercício da competência, que é quando o agente originariamente competente (delegante) confere a outro agente (delegado) o exercício temporário de algumas atribuições – essa delegação de competência pode ser revogada a qualquer tempo.

Portanto, delegar é transferir temporariamente o exercício da competência – empréstimo para outrem.

Para lembrar (já estudamos isso no material sobre "Atos Administrativos"):

- Subordinado ou superior: a delegação do exercício da competência pode ocorrer para agente ou órgão subordinado ou superior, ou seja, pode-se delegar para quem está acima ou abaixo na pirâmide hierárquica (art. 12, Lei Federal n.º 9.784/1999).

- Apenas o exercício: a delegação (e a avocação) de competência têm a ver com o seu exercício e não com a sua titularidade, ou seja, o que se transfere é o exercício da competência (a titularidade da competência sempre é intransferível).

- Revogável a qualquer tempo: a autoridade que delegou o exercício da competência para outrem pode revogar a delegação a qualquer tempo.

- Vedação ("No.R.Ex"): é vedado delegar o exercício da competência dos atos administrativos 'No.R.Ex' (art. 13, Lei Federal n.º 9.784/1999):

- Atos Normativos;
- Decisão de Recursos administrativos; e
- Atos de competência Exclusiva.

Lei Federal n.º 9.784/1999

Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.

Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:

- I - a edição de atos de caráter normativo;
- II - a decisão de recursos administrativos;
- III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.

e) Avocar competência: por fim, o poder hierárquico também admite a avocação da competência, que ocorre quando o superior hierárquico traz para si, temporariamente, o exercício de determinada competência conferida por lei a um subordinado seu.

Ou seja, avocar é chamar para si funções originariamente atribuídas a um subordinado.

Novamente para lembrar (também já estudamos isso no material sobre "Atos Administrativos"):

- Somente subordinado: o agente somente pode avocar o exercício da competência de agente ou órgão que lhe sejam hierarquicamente subordinados, ou seja, somente é possível avocar o exercício da competência de quem esteja abaixo na pirâmide hierárquica (art. 15, Lei Federal n.º 9.784/1999).

- Apenas o exercício: a avocação (e a delegação) de competência têm a ver com o seu exercício e não com a sua titularidade, ou seja, o que se transfere é o exercício da competência (a titularidade da competência jamais pode ser transferida).

- Vedação ("Ex"): é vedado avocar atos administrativos que sejam da competência exclusiva do órgão ou agente subordinado.

Lei Federal n.º 9.784/1999

Art. 15. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior.

5. PODER DISCIPLINAR

a) Conceito: o poder disciplinar é a faculdade que a Administração Pública possui para punir (internamente: estatuto) as infrações funcionais cometidas por seus agentes públicos e para punir (externamente: contrato) infrações administrativas cometidas por particulares a ela ligados mediante um vínculo jurídico específico.

b) Vínculo: o poder disciplinar (poder de punir) sempre exige um vínculo prévio entre a Administração Pública e o punido – o punido pode ser um agente público ou um particular. Quando a Administração (Poder Executivo) pune um particular com o qual não possui um vínculo prévio, está-se diante do Poder de Polícia (próximo tópico).

c) Punir: portanto, o poder disciplinar diz respeito ao poder de punição de que dispõe a Administração Pública (Poder Executivo).

Esse poder de punição pode ser exercido:

- *Internamente = agente público = estatuto:* a Administração tem o poder de, internamente, punir a infração funcional cometida pelos seus agentes públicos, com os quais possui um vínculo legal regido por meio de um estatuto.

O estatuto dos agentes públicos é uma lei. *Ex.:* Lei Federal n.º 8.112/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Federais).

Como vimos no tópico anterior, o Poder Público fiscaliza seus agentes com base no poder hierárquico; mas a punição é uma decorrência do poder disciplinar.

- *Externamente = particulares = contrato administrativo:* a Administração Pública também tem o poder de, externamente, punir a infração administrativa cometida por particular que tenha algum vínculo com ela, vínculo esse que se dará por meio de um contrato (vínculo contratual).

Ex.: as empresas delegatárias (concessionárias e permissionárias) de serviços públicos, que são pessoas jurídicas de direito privado (empresas particulares).

- *Particular sem vínculo = poder de polícia:* a Administração também pode punir particulares com os quais não tenha qualquer vínculo; mas aqui estaremos diante do poder de polícia (veremos adiante).

d) Poder disciplinar ≠ Poder hierárquico: como vimos acima, no tópico sobre Poder Hierárquico, os poderes hierárquico e disciplinar são correlatos, mas não podem ser confundidos:

- *Poder hierárquico (organizar):* o poder hierárquico, diz respeito à organização da Administração Pública, conforme visto no tópico anterior.

- *Poder disciplinar (punir):* o poder disciplinar, que estamos estudando agora, diz respeito ao poder de punição de que dispõe o Poder Público (Poder Executivo).

6. PODER DE POLÍCIA (POLÍCIA ADMINISTRATIVA)

a) Conceito: o poder de polícia administrativa é a faculdade de que dispõe a Administração Pública (Poder Executivo) para, em benefício da coletividade ou do próprio Estado, criar condições e restrições à forma pela qual os particulares em geral utilizarão seus bens, exercerão seus direitos e executarão as suas atividades (art. 78 do Código Tributário Nacional).

Código Tributário Nacional

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

b) Incidência: cuidar com a incidência do poder de polícia:

- *Incide*: bens + direitos + atividades;
- *Não incide*: pessoas.

Ex1: pessoa não habilitada que compra uma motocicleta e sai pilotando e fazendo manobras perigosas: o poder de polícia administrativa incide sobre o bem (motocicleta), que deve ter uma série de equipamentos de segurança e identificação, e também sobre o direito de conduzir a motocicleta, o qual inexistente para pessoas sem CNH.

Mas o poder de polícia administrativa não incide sobre a pessoa que está conduzindo a motocicleta – acaso essa pessoa tenha cometido um crime de trânsito, o que incidirá sobre ela é o poder de polícia judiciária.

Ex2: cidadão que resolve abrir um açougue e vender carnes sem procedência e acondicionadas em caixas de isopor: aqui o poder de polícia administrativa incidirá sobre a atividade desempenhada por essa pessoa (açougue), para a qual é necessária uma série de certificações e autorizações.

Mas, do mesmo modo, o poder de polícia administrativa não incide sobre a pessoa – acaso a situação também configure um crime, o que incidirá sobre essa pessoa é o poder de polícia judiciária.

→ **Polícia Administrativa** ≠ **Polícia Judiciária**: quando se fala em poder de polícia no âmbito do Direito Administrativo, estamos tratando especificamente da polícia administrativa, e não da polícia judiciária.

Para melhor compreender, segue quadro com a diferenciação de ambas.

Polícia Administrativa	Polícia Judiciária
- ilícitos de ordem administrativa; - eminentemente preventiva; - incide sobre bens + direitos + atividades; - exercida por vários órgãos: polícia civil, polícia federal, polícia militar, bombeiros, RFB, vigilância sanitária, guarda civil...	- ilícitos de ordem penal/criminal; - eminentemente repressiva; - incide sobre pessoas (prisão); - exercida, apenas, pela polícia civil e pela polícia federal.

Realizada a diferenciação, voltamos a tratar exclusivamente do poder de polícia administrativa.

c) Preventiva e repressiva: como visto no quadro acima, o poder de polícia administrativa possui natureza eminentemente preventiva; mas também possui natureza repressiva, que é a aplicação de sanções.

A sanção somente é aplicada em caso de descumprimento da ordem preventiva.

Ou seja, o não cumprimento da ordem (preventiva) gera a sanção (repressiva).

Ex.: o radar de velocidade veicular possui a finalidade de evitar que os motoristas ultrapassem o limite máximo de velocidade para aquele local (finalidade preventiva); mas, o motorista que ultrapassar o limite, será multado e sofrerá a imposição de pontos em sua CNH (finalidade repressiva).

d) Poder extroverso: extroverso é algo voltado para fora.

O poder de polícia administrativa é uma decorrência do poder extroverso ou poder de império do Estado, em que ele age em condição de superioridade em relação aos particulares.

6.1. Fases do Poder de Polícia

O poder de polícia possui quatro fases.

a) Ordem = norma jurídica (sempre): ocorre quando é criada a ordem a ser seguida, ou seja, é quando há a edição de uma norma jurídica (lei em sentido amplo) criando condições e restrições a bens, direitos e atividades.

A ordem é uma fase que sempre está presente no poder de polícia, pois se a ordem (norma jurídica) não existir, haverá liberdade plena aos particulares, não se falando em condições ou restrições ao uso e gozo de seus bens, direitos e atividades.

Portanto, sem a "ordem" sequer há poder de polícia.

Ex.: para conduzir um carro de corrida (em ambiente controlado), é obrigatório utilizar capacete; mas para conduzir um carro de passeio não (aqui não há norma, não há ordem que determine o uso de capacete).

b) Consentimento (as vezes): a fase de consentimento estará presente nas situações em que o particular precisará do consentimento da Administração Pública (Poder Executivo) para fazer o que pretende.

Ex.: para construir uma casa, preciso de um alvará de construção (preciso da anuência do Poder Público).

A fase de consentimento nem sempre estará presente, pois há diversas situações em que os particulares não precisam do consentimento do Poder Público para executar as atividades pretendidas.

Ex.: não preciso do consentimento do Poder Público para fazer a limpeza de um terreno de minha propriedade localizado na área urbana do município; mas se eu não fizer, corro o risco de ser multado.

c) Fiscalização (sempre): fiscalização é a verificação, por parte do Estado (Poder Executivo), do cumprimento da ordem (da norma jurídica).

O poder de fiscalização sempre está presente, mesmo que não ocorra de forma efetiva.

Ex.: toda e qualquer construção está sujeita a embargo ou demolição se executada sem observar as normas municipais; mesmo assim, não há um representante do Poder Público acompanhando em tempo integral todas as obras; mas, claro, se houver uma fiscalização e for constatada alguma irregularidade numa obra, poderá ser determinada a sua paralisação (embargo) ou demolição.

d) Sanção (as vezes): a sanção é a aplicação da penalidade ao particular que descumpriu a ordem (norma jurídica), o que nem sempre ocorre.

Ou seja, a sanção nem sempre está presente, pois nem todas as infrações são punidas.

Ex.: um motorista que não liga a seta ao mudar de faixa de rolamento, que ultrapassa em local proibido (linha contínua), que buzina próximo a hospitais, que fura o sinal... nem sempre é multado.

6.2. Delegação do Poder de Polícia

O poder de polícia pode ser delegado pelo Poder Executivo tanto para pessoas jurídicas de direito público quanto para pessoas jurídicas de direito privado.

a) Delegação do poder de polícia para PJ's de direito público: os donos do poder de polícia podem delegá-lo para pessoas jurídicas de direito público – os donos do poder de polícia são o Poder Executivo da Administração direta dos Entes Federados (U+E+DF+M).

- Integral (4 fases): para as PJ's de direito público, a delegação do poder de polícia pode ser integral, ou seja, podem ser delegadas as quatro fases acima vistas.

Portanto, o Poder Executivo da U+E+DF+M pode delegar integralmente o poder de polícia para as PJ's de direito público.

- Autarquias + Fundações públicas de direito público: as autarquias sempre são de direito público; já as fundações públicas podem ter natureza jurídica de direito público (estas poderão receber a delegação integral do poder de polícia) ou de direito privado (estas somente poderão receber a delegação das fases de consentimento e fiscalização: ver abaixo).

b) Delegação do poder de polícia para PJ's de direito privado (particulares): mas os donos do poder de polícia administrativa também podem delegá-lo para particulares, vale dizer, para PJ's de direito privado.

O cuidado que se deve ter é que, se a Administração Pública quiser delegar o poder de polícia para particulares, somente poderá delegar-lhes as fases de consentimento e fiscalização (jamais as fases de ordem e sanção).

Portanto, o Poder Executivo da U+E+DF+M pode delegar as fases de consentimento e fiscalização do poder de polícia para Pj's de direito privado, que são as abaixo seguintes.

- Fundações públicas de direito privado: como visto, as FP's podem ter natureza jurídica de direito público ou privado; aqui estamos tratando apenas das FP's de direito privado.

- Empresas públicas: as EP's sempre são de direito privado.

- Sociedades de economia mista: as SEM's sempre são de direito privado.

- PJ's em geral: aqui são as pessoas jurídicas constituídas por particulares.

Exemplo de delegação da fase de fiscalização: quem geralmente faz o controle (fiscalização) dos radares estáticos de limite de velocidade são empresas privadas contratadas pelo Poder Público, mas a aplicação da multa de trânsito (sanção) é realizada pela Administração (Poder Executivo). O mesmo ocorrer com a "Rek Pay", empresa privada que administra o estacionamento rotativo na área central de Jaraguá do Sul/SC: ela fiscaliza, mas quem aplica a multa de trânsito é o Município (Poder Executivo).

Exemplo de delegação da fase de consentimento: para realizar a ligação de energia elétrica é necessário o consentimento da empresa de distribuição de energia (é ilícito fazer "gato"), que em muitos locais é uma empresa privada, como a Light, no estado do Rio de Janeiro.

6.3. Atributos do Poder de Polícia

O poder de polícia possui três atributos.

a) Discricionariedade (fases de fiscalização e sanção): a discricionariedade significa que o agente público que está executando o poder de polícia administrativa possui uma margem de escolha (claro, sempre observados os limites dados pela norma jurídica).

A margem de escolha se refere às fases de fiscalização e sanção.

- Fiscalização: a polícia escolhe se hoje ela vai fazer uma blitz de veículos ou se vai apenas fazer as fiscalizações de rotina; se resolver fazer a blitz, os policiais militares escolhem quais veículos irão parar e fiscalizar.

- Sanção: a discricionariedade em relação à sanção ocorre quando a lei traz um limite mínimo e máximo a ser observado.

Ex.: as multas a serem aplicadas pela vigilância sanitária geralmente trazem uma graduação (como de um mil a cinquenta mil reais), cabendo ao fiscal, no caso concreto, decidir qual o valor da multa que aplicará (observadas a razoabilidade e a proporcionalidade).

Como contraponto, percebe-se que as multas por infração de trânsito possuem um valor fixo, ou seja, nesses casos, não há discricionariedade quanto ao valor da multa a ser aplicada.

b) Autoexecutoriedade: como já visto quando do estudo dos atributos dos atos administrativos, a autoexecutoriedade é a qualidade de compelir materialmente o administrado, independentemente de seu consentimento ou de ordem judicial, inclusive com o uso da força (requisição de força policial).

Significa que a Administração Pública (Poder Executivo) pode executar as suas decisões sem precisar de intervenção judicial nem do consentimento do particular e, ainda, sem precisar garantir contraditório e ampla defesa a este.

Exs.: interdição de estabelecimento, apreensão de mercadoria irregular, demolição de obra irregular.

- Não universal: também vimos no material sobre atos administrativos que a autoexecutoriedade é um atributo que nem sempre está presente (não é universal), pois nem todos os atos administrativos a possuem.

O exemplo clássico de ato administrativo que não possui autoexecutoriedade é o pagamento da multa: a aplicação da multa é autoexecutória (não precisa haver consentimento do particular nem do Poder Judiciário), mas sua satisfação não, pois se o particular não a pagar, o Poder Público não poderá tirar dinheiro dele à força (autoexecutoriedade), tendo de propor uma ação judicial (ou seja, aqui a Administração precisará do Poder Judiciário).

c) Coercibilidade: o poder de polícia administrativa é uma ordem, é coercitivo, impositivo (o Poder Público não pede; ele manda).

Não tem querer: a Administração Pública (Poder Executivo) não precisa ter a anuência do particular para exercitar o poder de polícia contra ele.

7. PODER NORMATIVO ou REGULAMENTAR

a) Conceito: poder regulamentar é a prerrogativa conferida ao chefe do Poder Executivo para editar decretos e regulamentos para a fiel execução das leis, nos termos do art. 84, inc. IV, parte final, da CRFB/1988.

Ou seja, trata-se da possibilidade de editar atos normativos com o objetivo de complementar ou regulamentar a lei.

Constituição Federal

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

b) Chefe do Poder Executivo: quem possui o poder regulamentar são os chefes do Poder Executivo, quais sejam:

- Presidente da República (União);
- Governadores (estados e DF); e
- Prefeitos (municípios).

c) Indelegável: o poder regulamentar ou normativo não pode ser delegado, tanto que o púnico do art. 84, CRFB/1988, não prevê o inc. IV entre as matérias passíveis de delegação.

Relembre-se, ademais, que é vedado delegar o exercício da competência dos atos administrativos "No.R.Ex":

- Atos Normativos;
- Decisão de Recursos administrativos; e
- Atos de competência Exclusiva.

d) Não inovar o ordenamento jurídico: ao exercer o poder regulamentar, o chefe do Poder Executivo não pode extrapolar os limites da lei que está sendo regulamentada, pois "*ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei*" (art. 5º, II, CF).

Ou seja, apenas a lei pode inovar no ordenamento jurídico, prevendo novos direitos e obrigações; os decretos e regulamentos não, jamais.

Além disso, o chefe do Executivo não pode inovar no ordenamento jurídico porque não possui a atribuição de criar leis: legislar é uma atribuição do Poder Legislativo – o poder que os chefes do Executivo possuem é apenas regulamentar, normatizar a lei criada pelo Poder Legislativo.

Portanto, o poder regulamentar:

- *Não pode contrariar os comandos legais; e*
- *Não pode criar+extinguir+alterar direitos e obrigações.*

e) Natureza derivada ou secundária: complementando o acima exposto, o poder regulamentar possui natureza derivada ou secundária, o que significa dizer que é dependente de um ato de natureza originária (e esse ato originário é a lei).

Aqui temos o seguinte: a Constituição Federal é o marco zero, sendo que a lei retira seu fundamento de validade da Constituição (a lei é o ato primário), ao passo que os decretos e regulamentos retiram seu fundamento de validade da lei (por isso eles são atos secundários).

-> CF -> leis (ato originário) -> decretos e regulamentos (atos secundários).

Ex.: uma lei municipal, aprovada pela Câmara de Vereadores (Poder Legislativo), autoriza o Poder Executivo a implementar, nos dias de semana, o rodízio de veículos leves no município com vistas a desafogar o trânsito (essa lei cria uma obrigação para os particulares, que não poderão utilizar seus veículos em determinado dia da semana), mas sem trazer maiores detalhes.

O prefeito poderá, então, por meio de um decreto ou regulamento, disciplinar como esse rodízio de veículos funcionará, dispondo que na segunda-feira não poderão circular os veículos cujas placas terminem em 1 e 2; na terça os terminados em 3 e 4... e assim por diante.

Mas o prefeito não poderá determinar que o rodízio se aplique a caminhões e que também ocorrerá nos fins de semana, pois a lei limitou a veículos leves e a dias de semana.

f) Forma de controle: o poder regulamentar exercido pelo chefe do Poder Executivo sujeita-se a controle externo exercido pelos demais Poderes (Legislativo e Judiciário).

Como o controle que um Poder exerce sobre outro é uma forma de intervenção (ferimento à separação dos Poderes), ele somente é admitido quando houver expressa autorização na Constituição Federal.

- Controle realizado pelo Poder Legislativo (art. 49, V, CF): a CF prevê que o Congresso Nacional (Poder Legislativo) possui o poder de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar.

Ou seja, no exemplo acima do rodízio de carros, se o chefe do Poder Executivo, ao editar o decreto ou regulamento, incluir motocicletas e/ou caminhões, essa parte do decreto poderá ser sustada (suspensa) pelo Poder Legislativo.

- Controle realizado pelo Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF): já o controle que é exercido pelo Poder Judiciário sobre o poder regulamentar exercido pelo chefe do Executivo ocorre através das ações judiciais, que podem ser propostas pelos particulares discutindo o excesso existente no decreto ou regulamento expedido pelo chefe do Poder Executivo.

Ainda no exemplo do rodízio de carros, o motorista que for multado em fim de semana por não observar o rodízio (ou caminhoneiro multado em qualquer dia da semana), poderá propor ação judicial requerendo a anulação da multa pelo fato de estar baseada em decreto ou regulamento que extrapolou os limites traçados pela lei, que impõe o rodízio apenas em dias da semana e para veículos leves.

Constituição Federal

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

8. ABUSO DE PODER

a) Uso do poder: quando a Administração Pública (Poder Executivo) utiliza as prerrogativas concedidas pelo ordenamento jurídico para a consecução dos fins públicos, estamos diante do uso do poder (uso legal, legítimo).

b) Abuso do poder: agora, quando a Administração utiliza de forma ilegítima das prerrogativas, estamos diante do abuso de poder (ilegal, ilegítimo).

O abuso de poder é sempre um ato ilegal, ou seja, um ato contrário à lei. Sendo assim, deve ser anulado.

-> ato administrativo ilegal = anulação = efeito *ex tunc* (art. 53, primeira parte, Lei Federal n.º 9.784/1999).

Lei Federal n.º 9.784/1999

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

c) Espécies de abuso do poder: o abuso do poder pode ser decorrente de excesso de poder, desvio de poder ou omissão.

- Excesso de poder (excesso de competência): no excesso de poder tem-se vício na competência (a competência é um dos elementos do ato administrativo: "CO.FI.FO.MO.OB"), gerando a nulidade do ato (art. 2º, 'a', Lei Nacional n.º 4.717/1965).

Ou seja, o agente público atua fora dos limites da sua esfera de competência, o que pode ocorrer de duas formas:

- O agente público pratica ato de competência de outrem;
- O agente público extrapola a sua própria competência.

- Desvio de poder (desvio de finalidade): no desvio de poder tem-se vício na finalidade (que também é um dos elementos do ato administrativo: "CO.FI.FO.MO.OB"), o que, do mesmo modo, gera a nulidade do ato (art. 2º, 'e', Lei Nacional n.º 4.717/1965).

Aqui o agente público, embora dentro de sua esfera de competência, afasta-se do interesse público quando pratica o ato administrativo, ou seja, busca alcançar fim diverso daquele que a lei lhe permitiu explícita ou implicitamente.

Ex.: praticar o ato para se vingar de alguém.

- Omissão: por fim, na omissão o agente público tem o dever de praticar o ato administrativo, mas não o faz, causando lesão a alguém.

Ex.: o particular faz o requerimento de licença para construir, mas a Administração nunca analisa o pedido.

Lei Nacional n.º 4.717/1965

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

- a) incompetência;
- e) desvio de finalidade.

9. QUESTÕES

- 01) ()** O poder vinculado informa que o Administrador público não poderá fazer mais nem menos que o determinado pela norma legal, pois não lhe subsiste qualquer margem de escolha.
- 02) ()** Quando há a opção entre praticar o ato de determinada maneira, estar-se-á diante do poder arbitrário da Administração pública.
- 03) ()** O poder hierárquico é a faculdade que a Administração Pública possui para punir as infrações funcionais cometidas por seus agentes públicos.
- 04) ()** No âmbito da descentralização administrativa, que é a possibilidade de os Entes da Administração direta criarem as Entidades da Administração indireta, há nítido poder hierárquico.
- 05) ()** A possibilidade de dar ordens, fiscalizar, controlar, delegar e avocar competências são decorrências diretas do poder hierárquico.
- 06) ()** Enquanto a avocação de competência somente pode ser de agente subordinado, a delegação pode ser para agente subordinado ou superior.
- 07) ()** A delegação e a avocação dizem respeito unicamente à titularidade da competência, nunca ao seu exercício.
- 08) ()** Quando o Poder Público pune particulares que não tenham vínculo consigo, está se utilizando do poder disciplinar.
- 09) ()** O poder de polícia conferido à Administração Pública diz respeito, lógica e apenasmente, às polícias em geral.
- 10) ()** As fases de consentimento e fiscalização do poder de polícia podem ser delegadas para particulares pela Administração Pública.
- 11) ()** Enquanto a coercibilidade é um atributo sempre presente no poder de polícia, o mesmo não se pode dizer em relação à autoexecutoriedade.
- 12) ()** O poder regulamentar é aquele concedido aos chefes do Poder Executivo para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis.
- 13) ()** Em virtude da sua natureza derivada ou secundária, o chefe do Poder Executivo poderá valer-se do poder normativo para inovar o ordenamento jurídico, criando novos direitos e obrigações.

Q852379

Ano: 2017 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2017 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XXIV - Primeira Fase

João foi aprovado em concurso público promovido pelo Estado Alfa para o cargo de analista de políticas públicas, tendo tomado posse no cargo, na classe inicial da respectiva carreira. Ocorre que João é uma pessoa proativa e teve, como gestor, excelentes experiências na iniciativa privada.

Em razão disso, ele decidiu que não deveria cumprir os comandos determinados por agentes superiores na estrutura administrativa, porque ele as considerava contrárias ao princípio da eficiência, apesar de serem ordens legais.

A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta.

- () A) João possui total liberdade de atuação, não se submetendo a comandos superiores, em decorrência do princípio da eficiência.
- () B) A liberdade de atuação de João é pautada somente pelo princípio da legalidade, considerando que não existe escalonamento de competência no âmbito da Administração Pública.
- () C) João tem dever de obediência às ordens legais de seus superiores, em razão da relação de subordinação decorrente do poder hierárquico.
- () D) As autoridades superiores somente podem realizar o controle finalístico das atividades de João, em razão da relação de vinculação estabelecida com os superiores hierárquicos.

Q369642

Ano: 2014 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2014 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XIII - Primeira Fase

José da Silva é o chefe do Departamento de Pessoal de uma Secretaria de Estado. Recentemente, José da Silva avocou a análise de determinada matéria, constante de processo administrativo inicialmente distribuído a João de Souza, seu subordinado, ao perceber que a questão era por demais complexa e não vinha sendo tratada com prioridade por aquele servidor.

Ao assim agir, José da Silva fez uso:

- () A) do poder hierárquico.
- () B) do poder disciplinar.
- () C) do poder discricionário.
- () D) da teoria dos motivos determinantes.

Q129214

Ano: 2010 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2010 - OAB - Exame de Ordem Unificado - II - Primeira Fase

A doutrina costuma afirmar que certas prerrogativas postas à Administração encerram verdadeiros poderes, que são irrenunciáveis e devem ser exercidos sempre que o interesse público clamar. Por tal razão são chamados poder-dever. A esse respeito é correto afirmar que:

- () A) o poder regulamentar é amplo, e permite, sem controvérsias, a edição de regulamentos autônomos e executórios.
- () B) o poder disciplinar importa à administração o dever de apurar infrações e aplicar penalidades, mesmo não havendo legislação prévia.
- () C) o poder de polícia se coloca discricionário, conferindo ao administrador ilimitada margem de opções quanto à sanção a ser, eventualmente, aplicada.
- () D) o poder hierárquico é inerente à ideia de verticalização administrativa, e revela as possibilidades de controlar atividades, delegar competência, avocar competências delegáveis e invalidar atos, dentre outros.

Q1040971

Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem Unificado XXX - Primeira Fase

Após comprar um terreno, Roberto iniciou a construção de sua casa, sem prévia licença, avançando para além dos limites de sua propriedade e ocupando parcialmente a via pública, inclusive com possibilidade de desabamento de parte da obra e risco à integridade dos pedestres.

No regular exercício da fiscalização da ocupação do solo urbano, o poder público municipal, observadas as formalidades legais, valendo-se da prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza-o a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade privada em favor do interesse da coletividade, determinou que Roberto demolisse a parte irregular da obra.

O poder administrativo que fundamentou a determinação do Município é o poder:

- () A) de hierarquia, e, pelo seu atributo da coercibilidade, o particular é obrigado a obedecer às ordens emanadas pelos agentes públicos, que estão em nível de superioridade

hierárquica e podem usar meios indiretos de coerção para fazer valer a supremacia do interesse público sobre o privado.

() B) disciplinar, e o particular está sujeito às sanções impostas pela Administração Pública, em razão do atributo da imperatividade, desde que haja a prévia e imprescindível chancela por parte do Poder Judiciário.

() C) regulamentar, e os agentes públicos estão autorizados a realizar atos concretos para aplicar a lei, ainda que tenham que se valer do atributo da autoexecutoriedade, a fim de concretizar suas determinações, independentemente de prévia ordem judicial.

() D) de polícia, e a fiscalização apresenta duplo aspecto: um preventivo, por meio do qual os agentes públicos procuram impedir um dano social, e um repressivo, que, face à transgressão da norma de polícia, redunde na aplicação de uma sanção.

Q852383

Ano: 2017 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2017 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XXIV - Primeira Fase

Um fiscal de posturas públicas municipais verifica que um restaurante continua colocando, de forma irregular, mesas para os seus clientes na calçada. Depois de lavrar autos de infração com aplicação de multa por duas vezes, sem que a sociedade empresária tenha interposto recurso administrativo, o fiscal, ao verificar a situação, interdita o estabelecimento e apreende as mesas e cadeiras colocadas de forma irregular, com base na lei que regula o exercício do poder de polícia correspondente.

A partir da situação acima, assinale a afirmativa correta.

() A) O fiscal atuou com desvio de poder, uma vez que o direito da sociedade empresária de continuar funcionando é emanção do direito de liberdade constitucional, que só pode ser contrastado a partir de um provimento jurisdicional.

() B) A prática irregular de ato autoexecutório pelo fiscal é clara, porque não homenageou o princípio do contraditório e da ampla defesa ao não permitir à sociedade empresária, antes da apreensão, a possibilidade de produzir, em processo administrativo específico, fatos e provas em seu favor.

() C) O ato praticado pelo fiscal está dentro da visão tradicional do exercício da polícia administrativa pelo Estado, que pode, em situações extremas, dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, atuar de forma autoexecutória.

() D) A atuação do fiscal é ilícita, porque os atos administrativos autoexecutórios, como mencionado acima, exigem, necessariamente, autorização judicial prévia.

Q490841

Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2015 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XVI - Primeira Fase

Determinado município resolve aumentar a eficiência na aplicação das multas de trânsito. Após procedimento licitatório, contrata a sociedade empresária Cobra Tudo para instalar câmeras do tipo "radar" que fotografam infrações de trânsito, bem como disponibilizar agentes de trânsito para orientar os cidadãos e aplicar multas. A mesma sociedade empresária ainda ficará encarregada de criar um Conselho de Avaliação das multas, com o objetivo de analisar todas as infrações e julgar os recursos administrativos.

Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta.

() A) É possível a contratação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, mas o poder decisório não pode ser transferido à empresa.

() B) Não é cabível a terceirização de qualquer dessas atividades, por se tratar de atividade-fim da Administração.

() C) A contratação é, a princípio, legal, mas somente permanecerá válida se o município comprovar que a terceirização aumentou a eficiência da atividade.

() D) Não é possível delegar a instalação e gestão de câmeras do tipo "radar" à empresa contratada, mas é possível delegar a criação e gestão do Conselho de Avaliação de multas.

Q423513

Ano: 2014 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2014 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XIV - Primeira Fase

A Secretaria de Defesa do Meio Ambiente do Estado X lavrou auto de infração, cominando multa no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) à empresa Explora, em razão da instalação de uma saída de esgoto clandestina em uma lagoa naquele Estado.

A empresa não impugnou o auto de infração lavrado e não pagou a multa aplicada.

Considerando o exposto, assinale a afirmativa correta.

- () A) A aplicação de penalidade representa exercício do poder disciplinar e autoriza a apreensão de bens para a quitação da dívida, em razão da executóriedade do ato.
- () B) A aplicação de penalidade representa exercício do poder de polícia e autoriza a apreensão de bens para a quitação da dívida, em razão da executóriedade do ato.
- () C) A aplicação de penalidade representa exercício do poder disciplinar, mas não autoriza a apreensão de bens para a quitação da dívida.
- () D) A aplicação de penalidade representa exercício do poder de polícia, mas não autoriza a apreensão de bens para a quitação da dívida.

Q349648

Ano: 2013 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2013 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XI - Primeira Fase

Atendendo a uma série de denúncias feitas por particulares, a Delegacia de Defesa do Consumidor (DECON) deflagra uma operação, visando a apurar as condições dos alimentos fornecidos em restaurantes da região central da capital. Logo na primeira inspeção, os fiscais constataram que o estoque de um restaurante tinha produtos com a validade vencida. Na inspeção das instalações da cozinha, apuraram que o espaço não tinha condições sanitárias mínimas para o manejo de alimentos e o preparo de refeições. Os produtos vencidos foram apreendidos e o estabelecimento foi interditado, sem qualquer decisão prévia do Poder Judiciário.

Assinale a alternativa que indica o atributo do poder de polícia que justifica as medidas tomadas pela DECON.

- () A) Coercibilidade.
- () B) Inexigibilidade.
- () C) Autoexecutoriedade.
- () D) Discricionariedade.

Q312316

Ano: 2013 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2013 - OAB - Exame de Ordem Unificado - X - Primeira Fase

Oscar é titular da propriedade de um terreno adjacente a uma creche particular. Aproveitando a expansão econômica da localidade, decidiu construir em seu terreno um grande galpão. Oscar iniciou as obras, sem solicitar à prefeitura do município "X" a necessária licença para construir, usando material de baixa qualidade. Ainda durante a construção, a diretora da creche notou que a estrutura não apresentava solidez e corria o risco de desabar sobre as crianças. Ao tomar conhecimento do fato, a prefeitura do município "X" inspecionou o imóvel e constatou a gravidade da situação. Após a devida notificação de Oscar, a estrutura foi demolida.

Assinale a afirmativa que indica o instituto do direito administrativo que autoriza a atitude do município "X".

- () A) Tombamento.
- () B) Poder de polícia.
- () C) Ocupação temporária.
- () D) Desapropriação.

Q197091

Ano: 2008 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: OAB Prova: CESPE - 2008 - OAB - Exame de Ordem - 2 - Primeira Fase

No que se refere aos poderes dos administradores públicos, assinale a opção correta.

- () A) O poder disciplinar caracteriza-se pela discricionariedade, podendo a administração escolher entre punir e não punir a falta praticada pelo servidor.
- () B) Uma autarquia ou uma empresa pública estadual está ligada a um estado-membro por uma relação de subordinação decorrente da hierarquia.
- () C) No exercício do poder regulamentar, a administração não pode criar direitos, obrigações, proibições, medidas punitivas, devendo limitar-se a estabelecer normas sobre a forma como a lei vai ser cumprida.
- () D) O poder de polícia somente pode ser exercido de maneira discricionária.

Q920998

Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2018 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XXVI - Primeira Fase

Maria solicitou ao Município Alfa licença de localização e funcionamento para exercer determinada atividade empresarial, apresentando todos os documentos necessários para tanto. Contudo, transcorrido mais de um ano do mencionado pedido, não houve qualquer manifestação por parte da autoridade competente para sua apreciação.

Diante dessa situação, na qualidade de advogado, assinale a afirmativa que indica o procedimento correto.

- () A) Não se pode adotar qualquer medida contra a inércia da autoridade competente, considerando que o princípio da razoável duração do processo não se aplica à via administrativa.
- () B) Deve-se ajuizar uma ação popular contra a omissão da autoridade competente, diante do preenchimento dos respectivos requisitos e da violação ao princípio da impessoalidade.
- () C) Deve-se impetrar mandado de segurança, uma vez que a omissão da autoridade competente para a expedição do ato de licença constitui abuso de poder.
- () D) Deve-se impetrar habeas data diante da inércia administrativa, considerando que a omissão da autoridade competente viola o direito à informação.

Q318807

Ano: 2008 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: OAB Prova: CESPE - 2008 - OAB - Exame de Ordem - 3 - Primeira Fase

O conselho diretor de uma autarquia federal baixou resolução disciplinando que todas as compras de material permanente acima de cinquenta mil reais só poderiam ser feitas pela própria sede. Ainda assim, um dos superintendentes estaduais abriu licitação para compra de microcomputadores no valor de trezentos mil reais. A licitação acabou sendo feita sem incidentes, e o citado superintendente homologou o resultado e adjudicou o objeto da licitação à empresa vencedora.

Nessa situação, o superintendente

- () A) agiu com excesso de poder.
- () B) agiu com desvio de poder.
- () C) cometeu mera irregularidade administrativa, haja vista a necessidade da compra e o atendimento aos requisitos de validade expressos na Lei de Licitações.
- () D) cometeu o crime de prevaricação, que consiste em praticar ato de ofício (a licitação) contra expressa ordem de superior hierárquico (a resolução do conselho diretor).

Q208746

Ano: 2006 Banca: ND Órgão: OAB-DF Prova: ND - 2006 - OAB-DF - Exame de Ordem - 3 - Primeira Fase

O dirigente de um órgão público, com o objetivo de prejudicar, por razões estritamente pessoais, determinado servidor público, efetiva a remoção desse último para localidade cinco vezes mais distante de sua residência (quando considerada a lotação anterior ao ato de movimentação funcional). Diante da situação apresentada é CORRETO afirmar que o ato administrativo praticado é:

- () A) lícito, apesar de inconveniente;
- () B) ilícito porque envolve um desvio de finalidade;

- () C) ilícito porque envolve uma manifestação de incompetência funcional;
- () D) ilícito porque envolve uma reversão fraudulenta.

SERVIÇOS PÚBLICOS

1. CONCEITO
 - 1.1. Critério Orgânico ou Subjetivo
 - 1.2. Critério Formal
 - 1.3. Critério Material
 - 1.4. Conclusão
2. PRINCÍPIOS
3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
 - 3.1. Gerais ou *Uti Universi* (Universal)
 - 3.2. Individuais ou *Uti Singuli* (Singular)
4. CENTRALIZAÇÃO e DESCENTRALIZAÇÃO
 - 4.1. Conceitos
5. PERMISSÃO e CONCESSÃO
 - 5.1. Regras Gerais da Permissão e da Concessão
 - 5.2. Prerrogativas do Poder Delegante
 - 5.3. Extinção da Permissão ou Concessão
 - 5.4. Efeitos da Extinção
6. PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP)
7. CONSÓRCIO PÚBLICO
8. QUESTÕES

Neste material iremos estudar como a Administração pública (Poder Executivo) presta os serviços públicos à população.

O foco não é estudar quais são os serviços públicos, mas sim como eles são disponibilizados ao povo.

1. CONCEITO

O conceito do que é serviço público vem evoluindo com o passar dos anos e pode ser fornecido a partir de três critérios: orgânico (subjeto), formal e material.

1.1. Critério Orgânico ou Subjetivo

O critério orgânico – ou subjetivo – leva em conta quem presta o serviço público. Assim, para esse critério, serviço público é aquele prestado diretamente pelo Estado.

Mas essa conceituação é tida como ultrapassada em decorrência da possibilidade de o serviço público também poder ser prestado indiretamente pelo Poder Público, o que se dá através da delegação da prestação dos serviços a particulares (permissão e concessão) – art. 175, CRFB/1988.

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

1.2. Critério Formal

Para o critério formal o que interessa é o regime jurídico do serviço prestado.

Dessa forma, será serviço público qualquer atividade realizada sob o regime de direito público e que ofereça utilidade material à sociedade.

Ocorre que em algumas situações os serviços públicos são prestados sob regras de direito privado, como ocorre quando são prestados por empresas públicas (ex.: CEF, Correios) ou sociedades de economia mista (ex.: BB e Petrobrás), as quais se submetem ao "[...] *regime jurídico próprio das empresas privadas* [...]" – art. 173, § 1º, II, CRFB/1988 –, ou seja, ao direito privado.

Constituição Federal

Art. 173. [...]

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;

1.3. Critério Material

Por fim, segundo o critério material, há certas atividades que devem ser consideradas públicas em decorrência da sua natureza. Portanto, para este critério, o que define serviço público é a natureza do próprio serviço.

Então, é considerado serviço público toda atividade que tem por objeto a satisfação das necessidades da coletividade.

O problema é que essa conceituação acaba abarcando uma série de atividades essenciais que não são serviço público porque são prestadas por particulares sem a necessidade de delegação por parte do Poder Público, como a educação em escolas particulares e os serviços de saúde em clínicas e hospitais também particulares.

1.4. Conclusão

Sendo assim, não existe um conceito uniforme que nos indique o que sejam os serviços públicos.

O pai do Direito Administrativo brasileiro, Hely Lopes Meirelles, conceitua serviço público como *"[...] todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples conveniências do Estado"*.

Portanto, pode-se dizer que serviço público é toda atividade exercida direta ou indiretamente pelo Poder Público com o escopo de prover necessidades essenciais do cidadão, da sociedade em geral e do próprio Estado.

2. PRINCÍPIOS

Os princípios são guias norteadores para a análise de uma determinada matéria.

No dizer de Miguel Reale, "[...] *toda forma de conhecimento filosófico ou científico implica a existência de princípios, isto é, de certos enunciados lógicos admitidos como condição ou base de validade das demais asserções que compõem dado campo do saber*".

a) "L.I.M.P.E" (art. 37, caput, CRFB/1988): como não poderia deixar de ser, aos serviços públicos também se aplicam os princípios básicos da Administração pública, que são aqueles constantes do caput do art. 37 da CRFB/1988, o famoso mnemônico "L.I.M.P.E": legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Já estudamos esses princípios – e vários outros – no material "Noções Preliminares"; mas além desses princípios que formam o mnemônico "L.I.M.P.E", os serviços públicos também possuem princípios específicos, que estão previstos no § 1º do art. 6º da Lei Nacional n.º 8.987/1995 – esta é a Lei que trata dos serviços públicos, mencionada no púnico do art. 175 da CRFB/1988.

Constituição Federal

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - [...]

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária;

IV - a obrigação de manter serviço adequado.

Lei Nacional n.º 8.987/1995

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

b) Isonomia ou igualdade: a igualdade na prestação do serviço público deve ser tanto formal quanto material – abaixo uma imagem que bem demonstra a diferença entre essas duas formas de igualdade (à esquerda a igualdade formal; à direita, a material):



Ex. de igualdade material: ações afirmativas, como cotas para ingresso em universidades públicas, passagem de ônibus mais barata para estudantes.

Vale lembrar a célebre frase do patrono da advocacia brasileira, Rui Barbosa, sobre a igualdade:

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desiguam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade... Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real.

c) Regularidade: é dever do Estado prestar os serviços públicos, direta ou indiretamente, de maneira regular, de modo que não cause surpresas indesejáveis à população.

Ex.: o ônibus do transporte público urbano deve passar nos pontos todos os dias úteis nos mesmos horários, de forma regular.

d) Continuidade: significa que o serviço público não pode ser interrompido, pois a satisfação dos direitos fundamentais da sociedade é uma necessidade constante.

Exceções: entretanto, há situações que não caracterizam descontinuidade do serviço público – são as exceções, previstas no art. 6º, § 3º, da Lei Federal n.º 8.987/1995, que seguem abaixo.

- Em situação de emergência, interrupção por razões de ordem técnica ou para a segurança das instalações: nessa situação, não é necessário haver aviso prévio aos usuários, justamente por se tratar de situação de emergência.

Ex.: numa tempestade a Celesc desativa o fornecimento de energia elétrica em virtude de risco de incêndio na central de distribuição, sendo desnecessário avisar previamente os usuários.

- Após aviso prévio, interrupção por razões de ordem técnica ou para a segurança das instalações: percebe-se que aqui é necessário que os usuários sejam previamente avisados sobre a interrupção do serviço público.

Ex.: Samae avisa que, em determinado dia e horário, interromperá o fornecimento de água potável de algum bairro porque precisa fazer manutenção na rede de abastecimento.

- Após aviso prévio, interrupção por inadimplemento do usuário: por fim, quando se trata de serviço público pago, sua interrupção pode ocorrer em virtude do inadimplemento do usuário, pois a sua continuidade pressupõe a devida contraprestação pecuniária.

Mas aqui, como na situação acima, o usuário inadimplente deve ser previamente avisado de que o serviço público será interrompido.

Ex.: empresa de telefonia suspende o pacote de voz e dados do usuário porque este, mesmo tendo sido avisado sobre o inadimplimento na fatura anterior, não efetuou o pagamento do débito.

- Exceção: direitos fundamentais essenciais (exceção da exceção): mas a interrupção, mesmo havendo o inadimplimento do usuário, não pode ocorrer quando afetar direitos fundamentais essenciais.

Ex1: a concessionária de energia elétrica não pode cortar o fornecimento da energia quando há na casa pessoa doente (*home care*) que sobrevive com a ajuda de aparelhos elétricos.

Ex2: também não pode ocorrer o corte de energia ou água potável de um hospital público; mas pode haver o corte se for de um ginásio de esportes ou de uma piscina pública, pois estes não dizem respeito a direitos fundamentais essenciais.

Lei Nacional n.º 8.987/1995

Art. 6º [...]

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplimento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

§ 4º A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso II do § 3º deste artigo não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado.

e) Eficiência: a Administração deve buscar o constante aprimoramento dos serviços públicos, que devem atender de maneira satisfatória toda a coletividade.

A prestação do serviço público deve se dar de modo que atenda efetivamente às necessidades da coletividade, do usuário e do Estado, com o maior aproveitamento possível e com baixo custo.

Inclusive, há previsão expressa na Constituição Federal nesse sentido destinada aos particulares colaboradores que prestam serviços públicos por meio de permissão e concessão (delegatários) – art. 175, púnico, IV.

Constituição Federal

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

IV - a obrigação de manter serviço adequado.

f) Segurança: a prestação dos serviços públicos não pode colocar em risco a integridade física nem psíquica dos usuários ou a segurança da coletividade.

g) Atualidade ou adaptabilidade: o serviço público deve ser prestado mediante tecnologias modernas, atuais – não precisam ser tecnologias de ponta; mas também não devem ser tecnologias obsoletas.

Ex.: a frota dos ônibus do transporte público deve ser renovada com regularidade (não podem ser utilizados ônibus com vários anos de fabricação).

h) Generalidade, universalidade ou igualdade dos usuários: os serviços públicos devem ser disponibilizados a todos ou ao maior número possível de pessoas de maneira igualitária (ex.: saúde, educação, segurança, saneamento básico), sem discriminação ou direcionamento a apenas algumas camadas da população.

Por isso também é conhecido como princípio da igualdade dos usuários.

- Limitador: princípio da reserva do possível: para a Administração Pública respeitar o princípio da generalidade e atingir o maior número possível de pessoas, são necessários recursos que o Estado muitas vezes não possui.

É aqui que entra o princípio da reserva do possível, ou seja, devem ser observadas as possibilidades da Administração, pois enquanto as necessidades são infinitas, os recursos públicos são finitos.

Portanto, o princípio da universalidade é limitado pelo princípio da reserva do possível.

i) Cortesia e urbanidade: significa que o usuário deve sentir-se acolhido pelo serviço público, ou seja, quem presta serviços públicos deve fazê-lo de maneira respeitosa e sempre buscando atender de maneira correta o usuário, pois este é a verdadeira razão de ser do serviço público.

j) Modicidade das tarifas: os serviços públicos devem ser prestados a custo baixo para garantir o acesso a toda a população (ex.: tarifas de água, telefone, ônibus, metrô).

O custo não pode tornar-se um fato impeditivo para a fruição do serviço público pela coletividade: a modicidade está associada à acessibilidade, exigindo que a política tarifária observe os recursos econômicos dos usuários dos serviços públicos (art. 175, púnico, III, CRFB/1988).

- Saúde financeira: mas, ao mesmo tempo, também deve ser garantida a saúde financeira de quem presta o serviço público, sobretudo quando ele é prestado por particulares (delegação: concessão e permissão – art. 175, CRFB/1988).

Para tanto, admite-se que as empresas permissionárias e concessionárias de serviços públicos utilizem fontes alternativas de receita, o que ajuda a reduzir o custo do serviço e alcançar a modicidade das tarifas.

Ex.: publicidade nos ônibus de transporte coletivo.

Constituição Federal

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

III - política tarifária;

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

A prestação dos serviços públicos observa o princípio da generalidade; mas a utilização dos serviços públicos pode ser universal ou singular.

3.1. Gerais ou *Uti Universi* (Universal)

Serviços públicos gerais são aqueles prestados a toda a coletividade indistintamente, de forma simultânea.

Os serviços públicos *uti universi* são indivisíveis, pois não é possível mensurar a utilização individual que cada usuário faz daquele determinado serviço público.

Dito de outro modo, os usuários dos serviços públicos gerais ou universais são indeterminados ou indetermináveis.

Ex.: iluminação pública, segurança pública, limpeza urbana, serviços administrativos em geral...

a) Remunerados por meio de impostos: como não é possível saber quanto cada usuário utiliza dos serviços públicos *uti universi*, a cobrança por eles somente é realizada pelo Poder Público por meio de impostos.

Ou seja, os usuários pagam pelos serviços públicos gerais ou universais por meio de impostos: esses serviços públicos são custeados pelos valores arrecadados por meio de impostos.

3.2. Individuais ou *Uti Singuli* (Singular)

Apesar de os serviços públicos serem prestados a todos indistintamente, há situações em que é possível medir quanto cada usuário utiliza, caso em que se configuram como serviços públicos individuais.

Os serviços públicos *uti singuli* são específicos, pois visam a satisfação individual e direta das necessidades do cidadão que utiliza o serviço.

Ex.: água tratada, energia elétrica, transporte público...

a) Remunerados por meio de taxas ou tarifas: como é possível mensurar a utilização individual que cada usuário faz do serviço público singular (individual ou *uti singuli*), o custo desses serviços é cobrado individualmente de cada usuário, o que é feito por meio de taxas ou tarifas (e não através de impostos).

b) Taxas (art. 145, II, CRFB/1988): quando estamos diante de regime legal (lei), o serviço público é remunerado por meio de taxas – regime legal significa que o serviço é prestado por uma Entidade administrativa, ou seja, pela Administração indireta (A+FP+EP+SEM).

Chama-se regime legal porque as Entidades da Administração indireta estão expressamente previstas em lei, *in casu*, na Constituição Federal (inc. XIX do art. 37) e no Decreto-lei Federal n.º 200/1967.

Ex.: o pagamento da fatura de água e esgoto do Samae é uma taxa, pois o Samae é uma autarquia.

Constituição Federal

Art. 37. [...]

XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

Decreto-lei Federal n.º 200/1967

Art. 4º A Administração Federal compreende:

I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.

II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria:

- a) Autarquias;
- b) Empresas Públicas;
- c) Sociedades de Economia Mista.
- d) fundações públicas.

Parágrafo único. As entidades compreendidas na Administração Indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade.

c) Tarifas (preço público): já quando se trata de regime contratual, o serviço público é remunerado por meio de tarifas – regime contratual é aquele no qual o serviço é prestado por um particular que firmou um contrato de permissão ou concessão com o Poder Público.

Ou seja, são as empresas permissionárias ou concessionárias de serviços públicos (segunda parte do *caput* do art. 175, CRFB/1988).

Ex1: nos municípios onde o serviço de saneamento foi concedido à iniciativa privada por meio de permissão ou concessão, o pagamento da fatura de água e esgoto é uma tarifa.

Ex2: também é tarifa o pagamento de pedágio à concessionária CCR Via Costeira (BR 101), das faturas da Vivo, Claro, Oi, TIM... (concessionárias de telefonia).

Constituição Federal

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

4. CENTRALIZAÇÃO e DESCENTRALIZAÇÃO

A centralização e a descentralização dizem respeito às formas de prestação dos serviços públicos, os quais podem ser prestados pelos Entes Federados de forma direta – centralização: U+E+DF+M (Administração direta) – ou indireta – descentralização: A+FP+EP+SEM (Administração indireta) + delegação (particulares).

→ Formas de Prestação dos Serviços Públicos:

1. Centralização;
2. Descentralização;
 - 2.1. Descentralização por serviços ou outorga legal;
 - 2.2. Descentralização por colaboração ou delegação;
 - 2.2.1. Permissão;
 - 2.2.2. Concessão;
 - 2.2.2.1. Concessão comum;
 - 2.2.2.1.1. Concessão comum de serviço público;
 - 2.2.2.1.2. Concessão comum de serviço público precedida de obra;
 - 2.2.2.2. Parceria Público-privada (PPP);
 - 2.2.2.2.1. Concessão patrocinada;
 - 2.2.2.2.2. Concessão administrativa;
3. Consórcios Públicos.

4.1. Conceitos

Agora passamos a estudar os conceitos do organograma acima; para facilitar, os números são repetidos abaixo.

1. Centralização

Centralização significa que o serviço público é prestado diretamente pelo seu titular.

Os titulares dos serviços públicos são os próprios Entes Federados, ou seja, a Administração direta:

- *União;*
- *Estados;*
- *Distrito Federal;*
- *Municípios.*

2. Descentralização

Na descentralização, o serviço público não é prestado pelo seu titular.

Aqui o serviço público é prestado por uma pessoa diferente da Administração direta, ou seja, não são os Entes Federados (U+E+DF+M) quem prestarão os serviços públicos, mas sim a Administração indireta ou os particulares.

- Administração indireta (descentralização por serviços ou outorga legal):
 - *Autarquias;*
 - *Fundações Públicas;*
 - *Empresas Públicas;*

- *Sociedades de Economia Mista.*

- Particulares (descentralização por colaboração ou delegação):

- Permissão;
- Concessão

2.1. Descentralização por serviços ou outorga legal (art. 37, XIX, CRFB/1988)

Aqui o serviço público é prestado por uma Entidade administrativa (Administração indireta: A+FP+EP+SEM), para a qual a lei transfere a titularidade e a execução.

Ou seja, a Administração direta (U+E+DF+M), que é a titular do serviço público, cria uma Entidade da Administração indireta (A+FP+EP+SEM) e lhe transfere a prestação do serviço público.

Nessa situação (Administração direta -> Administração indireta), ocorre a transferência tanto da prestação do serviço público quanto da sua própria titularidade.

Chama-se de outorga legal porque decorre da lei, conforme disposto no inc. XIX do art. 37 da CRFB/1988 e no Decreto-lei Federal n.º 200/1967.

a) Peculiaridades: quando a Administração direta cria uma Entidade da Administração indireta para a prestação de serviços públicos, temos o seguinte:

- Chamada de descentralização por serviço ou outorga legal;
- A transferência se dá do Ente Federado (Administração direta: U+E+DF+M) para alguma Entidade administrativa (Administração indireta: A+FP+EP+SEM);
- O Ente Federado transfere tanto execução quanto a titularidade do serviço público;
- Decorre de lei.

Constituição Federal

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

2.2. Descentralização por colaboração ou delegação (art. 175, caput, CRFB/1988)

Aqui o serviço público é prestado por particulares, mediante delegação do Poder Público, que lhes transfere apenas a execução (os particulares nunca detêm a titularidade do serviço público).

Ou seja, a Administração direta (U+E+DF+M), que é a titular do serviço público, transfere o mesmo para um particular, o que ela faz por meio dos institutos da concessão ou permissão de serviços públicos.

A escolha do particular – que pode ser PJ ou PF – se dá por meio de licitação; após, esse particular assinará um contrato com o Ente Federado, no qual estarão previstos os direitos e deveres de ambos.

a) Peculiaridades: quando a Administração direta transfere a prestação de serviços públicos para particulares (PF ou PJ), temos o seguinte:

- Chamada de descentralização por colaboração ou delegação;
- A transferência se dá do Ente Federado (Administração direta: U+E+DF+M) para um particular (PF ou PJ);
- O Ente Federado transfere apenas a execução serviço público (a titularidade continua com o Ente Federado);
- Ocorre mediante delegação, nas modalidades de concessão ou permissão (haverá uma licitação para a escolha do particular).

Constituição Federal

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

2.2.1. Permissão (inc. IV do art. 2º da Lei Nacional n.º 8.987/1995)

Na descentralização por colaboração ou delegação por meio de permissão, o Ente Federado transfere para um particular (PJ ou PF) a execução (nunca a titularidade) de um serviço público, mediante qualquer modalidade de licitação, para que o particular o exerça em seu próprio nome e por sua conta e risco, mediante tarifa (regime contratual) paga pelo usuário. A permissão de serviços públicos sofreu substancial alteração nas últimas décadas, conforme consta abaixo.

a) Doutrina tradicional (ato precário): para a doutrina tradicional, a permissão "[...] é o ato administrativo negocial, discricionário e precário, pelo qual o Poder Público faculta ao particular a execução de serviços de interesse coletivo, ou o uso especial de bens públicos, a título gratuito ou remunerado, nas condições estabelecidas pela Administração" (Hely Lopes Meirelles);

- Ato ≠ contrato: ou seja, para a doutrina tradicional, a permissão é um ato precário.

Ato precário é aquele que o Poder Público pode revogar a qualquer momento, sem que caiba indenização ao particular; portanto, para a doutrina tradicional, o Poder Público pode revogar, a qualquer momento, a permissão de serviço público concedida ao particular, sem que este tenha direito à indenização em virtude dessa revogação.

Se fosse um contrato administrativo, a revogação da permissão somente poderia ocorrer nas hipóteses expressamente previstas no contrato, sob pena de indenização.

b) Doutrina moderna (contrato administrativo): ocorre que o *caput* do art. 175 da CRFB/1988 passou a exigir a realização de licitação para a permissão e o art. 40 da Lei Nacional n.º 8.987/1995 menciona que a permissão é um contrato de adesão precário (o inc. IV do art. 2º da mesma lei menciona que a permissão é uma delegação a título precário, mediante licitação).

Por isso, a doutrina moderna entende que a permissão de serviço público passou a ser um contrato administrativo, e não mais um ato precário.

- Licitação + contrato: desse modo, como a CRFB/1988 passou a exigir a realização de licitação e a formalização de um contrato para que o Ente Federado possa conceder um serviço público à iniciativa privada mediante permissão, não é mais possível dizer que se trata de um ato precário, pois a regra de um contrato é que seja sinalagmático, ou seja, que contenha direitos e obrigações recíprocos.

Portanto, se o Poder Público revogar a permissão antes do prazo e fora das hipóteses expressamente previstas no contrato, caberá indenização ao particular.

Assim, conforme o entendimento doutrinário atual, a permissão de serviços públicos passou a ser um contrato administrativo que não é precário, tanto que o parágrafo único do art. 40 da Lei Nacional n.º 8.987/1995 menciona que se lhe aplicam as mesmas regras da concessão de serviços públicos ("*Aplica-se às permissões o disposto nesta Lei*").

- Cuidado: apesar de ser tecnicamente equivocado falar em contrato precário, se a questão mencionar que a permissão é um contrato precário, estará correta porque é essa a previsão expressa contida na Lei Nacional n.º 8.987/1995.

c) Peculiaridades: dessa forma, na permissão temos as seguintes peculiaridades:

- Licitação: deve ser realizada licitação para a escolha do particular que prestará o serviço público; essa licitação pode ser sob qualquer modalidade;
- Contrato administrativo: escolhido o particular, ele e o Ente Federado formaliza um contrato, no qual estarão previstos os direitos e deveres de cada um;
- Precário***: a lei menciona que esse contrato é precário;
- PF ou PJ: o permissionário (particular) pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica;
- Não depende de autorização legislativa: como veremos abaixo, a concessão depende de anuência do Poder Legislativo; mas a permissão não.

Lei Nacional n.º 8.987/1995

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:

IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário***, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

Art. 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade*** e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente.

Parágrafo único. Aplica-se às permissões o disposto nesta Lei.

2.2.2. Concessão (inc. II do art. 2º da Lei Nacional n.º 8.987/1995)

Na descentralização por colaboração ou delegação por meio de concessão, o Ente Federado transfere a um particular (PJ ou consórcio de PJs) a execução (nunca a titularidade) de um serviço público, mediante licitação nas modalidades concorrência ou diálogo competitivo, para que o particular o exerça em seu próprio nome e por sua conta e risco, mediante tarifa (regime contratual) paga pelo usuário.

Mas para que se possa transferir a execução de um serviço público mediante concessão, deve haver autorização legislativa por meio de uma lei (*caput* do art. 2º da Lei Nacional n.º 9.074/1995); ou seja, o Poder Executivo somente poderá fazer a concessão se houver anuência do Poder Legislativo.

a) Peculiaridades: dessa forma, na concessão temos as seguintes peculiaridades:

- Depende de autorização legislativa: deve haver uma lei específica autorizando a concessão (participação do Poder Legislativo);
- Licitação nas modalidades diálogo competitivo ou concorrência: a escolha do particular deve dar-se por meio de licitação, e nas modalidades concorrência ou diálogo competitivo;
- PJ ou consórcio de PJs: o particular tem que ser uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas (não pode ser PF, como ocorre na permissão);
- Contrato administrativo: escolhido o particular (PJ ou consórcio de PJs) por meio da licitação (concorrência ou diálogo competitivo), ele e o Ente Federado formaliza um contrato, no qual estarão previstos os direitos e deveres de cada um;

2.2.2.1.2. Concessão comum de serviço público precedida de obra (inc. III do art. 2º da Lei Nacional n.º 9.987/1995)

Na concessão comum de serviço público precedida de obra, temos um plus em relação à concessão vista acima ("2.2.2.1.1."), qual seja, a execução de uma obra pela empresa que prestará o serviço público.

Funciona assim: o Ente Federado deve ser autorizado pelo Poder Legislativo (lei específica) a realizar a concessão; o Ente, então, realiza uma licitação nas modalidades concorrência ou diálogo competitivo; a PJ ou consórcio de PJ's vencedor do certame assina um contrato com o Ente Federado para executar a obra e prestar o serviço público; esse contrato será por prazo determinado; a empresa, por sua conta e risco, executa a obra (quem pagará pela obra é a própria empresa); uma vez executada a obra, a empresa, também por sua conta e risco, passa a prestar o serviço público para o usuário durante o prazo contratual; e o usuário remunera diretamente a empresa por meio do pagamento de tarifa (não é o Poder Público quem remunera a empresa), que passa a amortizar o investimento realizado.

Ex.: contratação de uma empresa para construir um metrô e depois explorar o serviço.

Lei Nacional n.º 8.987/1995

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:

III - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegados pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado;

2.2.2.2. Parceria Público-privada (PPP)

A concessão na modalidade PPP pode ser:

- *Concessão patrocinada* ("2.2.2.2.1."); ou
- *Concessão administrativa* ("2.2.2.2.2.).

2.2.2.2.1. PPP: concessão patrocinada (art. 2º, § 1º, Lei Nacional n.º 11.079/2004)

É a concessão de serviços públicos ou de obras públicas que envolve, além da tarifa cobrada dos usuários, uma contraprestação pecuniária do parceiro público (do Ente Federado).

Ou seja, além da tarifa paga pelos usuários para remunerar a empresa concessionária, esta também recebe remuneração do próprio Poder Público concedente: a ideia é garantir a modicidade das tarifas.

Ex.: a concessão do metrô de Salvador/BH foi na modalidade patrocinada, onde parte do valor do bilhete é pago pelo próprio Município.

a) Peculiaridades: na PPP patrocinada temos o seguinte:

- Regra: 70x30%: a regra é que o valor pago pela Administração seja de, no máximo, 70% da remuneração do parceiro privado.

Dessa forma, se o Ente Federado concedente pagar 70%, o usuário pagará os outros 30%.

- Exceção (lei específica): +70%: mas há a possibilidade de o Ente Federado pagar mais de 70% da remuneração do parceiro privado; para tanto, precisará haver autorização legislativa específica, que ocorre por meio de lei.

Ou seja, o Poder Legislativo terá de autorizar o Poder Executivo a fazer essa PPP patrocinada com incentivo superior a 70%.

- Contraprestação variável (desempenho da concessionária): a remuneração a ser paga pela Administração também poderá ser variável, vinculada ao desempenho do parceiro privado, conforme metas e padrões de qualidade que serão definidos no contrato.

- Contraprestação após disponibilização do serviço: mas a contraprestação do Poder Público somente poderá ser paga a partir do momento em que houver a disponibilização do serviço público aos usuários, seja total ou parcialmente.

- Meios da contraprestação: por fim, a contraprestação do Ente Federado concedente não precisa ser necessariamente em dinheiro, podendo ocorrer por meio de:

- *Ordem bancária;*
- *Cessão de créditos não tributários;*
- *Outorga de direitos em face da Administração Pública;*
- *Outorga de direitos de bens dominicais; e*
- *Outros meios admitidos em lei.*

Lei Nacional n.º 11.079/2004

Art. 2º Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa.

§ 1º Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.

§ 2º [...]

2.2.2.2.2. PPP: concessão administrativa (art. 2º, § 2º, Lei Nacional n.º 11.079/2004)

A parceria público-privada para a concessão administrativa de serviços públicos é o contrato em que o próprio Poder Público é o usuário do serviço, pagando 100% da remuneração da empresa privada contratada.

Ex.: o Ente Federado contrata uma empresa para construir e gerenciar um presídio – obviamente não serão os presos quem pagarão a remuneração da concessionária, mas o próprio Ente Federado.

Lei Nacional n.º 11.079/2004

Art. 2º Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa.

§ 2º Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.

3. Consórcios públicos (art. 241, CRFB/1988)

Por fim, consórcio público é a modalidade em que dois ou mais Entes Federados se unem para prestar determinado serviço público.

Ou seja, é a gestão associada de Entes Federados (U+E+DF+M) visando melhor prestar os serviços públicos (art. 241, CRFB/1988).

Ex.: consórcio público entre a União e os Estados da BA, PE e CE para levar água potável aos moradores do semiárido nordestino.

Constituição Federal

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.

5. PERMISSÃO e CONCESSÃO

Aqui estudaremos as regras gerais das concessões de serviços públicos, as quais estão dispostas na Lei Nacional n.º 8.987/1995, que "*Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências*".

No que couber, essas regras também são aplicáveis às permissões de serviços públicos, conforme art. 40, púnico, da mencionada Lei.

Lei Nacional n.º 8.987/1995

Capítulo XI DAS PERMISSÕES

Art. 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente.

Parágrafo único. Aplica-se às permissões o disposto nesta Lei.

~~1. Centralização~~

~~2. Descentralização~~

~~2.1. Descentralização por serviços ou outorga legal~~

~~2.2. Descentralização por colaboração ou delegação~~

~~2.2.1. Permissão~~

~~2.2.2. Concessão~~

~~2.2.2.1. Concessão comum~~

~~2.2.2.1.1. Concessão de serviço público~~

~~2.2.2.1.2. Concessão de serviço público precedida de obra~~

~~2.2.2.2. Parceria Público-privada (PPP)~~

~~2.2.2.2.1. Concessão patrocinada~~

~~2.2.2.2.2. Concessão administrativa~~

~~3. Consórcios Públicos~~

5.1. Regras Gerais da Permissão e da Concessão

a) Licitação: a escolha do particular que executará o serviço público deve se dar meio de licitação.

- Concessão (concorrência ou diálogo competitivo): na concessão, a escolha do particular (PJ ou consórcio de PJ's) dar-se-á por licitação nas modalidades concorrência ou diálogo competitivo.

A peculiaridade é que o edital pode prever inversão nas fases de habilitação e classificação, ou seja, primeiro classifica os preços e depois habilita as empresas (igual ao leilão).

- Permissão (qualquer modalidade): na permissão, a licitação pode ser em qualquer modalidade licitatória.

b) Particular: o particular que pode prestar o serviço público também é diferente conforme se trate de concessão ou permissão.

- Concessão (PJ ou consórcio de PJ's): nas concessões, o particular contratado para a prestação do serviço público deve ser uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas (PJ ou consórcio de PJ's); jamais uma pessoa física.

- Permissão (PJ ou PF): já na permissão, o serviço público pode ser delegado tanto para uma pessoa jurídica quanto para uma pessoa física.

c) Arbitragem (art. 23-A, Lei Nacional n.º 8.987/1995): na concessão e na permissão, pode-se recorrer à arbitragem para solucionar controvérsias entre a concessionária ou permissionária e o Poder Público, de modo que não seja necessário levar a questão ao Poder Judiciário.

Mas a possibilidade da arbitragem deve estar expressamente prevista no edital da licitação e também no contrato formalizado entre a concessionária ou permissionária e o Ente Federado concedente.

A adoção da arbitragem traz as consequências abaixo.

- Maior celeridade na solução dos conflitos: os processos perante o Poder Judiciário costumam demorar mais para ter solução final.

- Ausência de submissão ao regime do precatório: o regime do precatório incide apenas no âmbito judicial (processo perante o Poder Judiciário).

A decisão arbitral é um mecanismo privado de solução de conflitos e, portanto, não se submete ao regime dos precatórios.

Lei Nacional n.º 8.987/1995

Art. 23-A. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.

d) Ausência de exclusividade (art. 16, Lei Nacional n.º 8.987/1995): a regra é que o serviço público seja delegado à concessionária ou permissionária sem caráter de exclusividade.

Ex.: foi realizada uma licitação e contratada uma empresa para prestar o serviço público de transporte urbano de passageiros; se, dois anos depois, o Poder Público sentir a necessidade de ampliar o serviço, pode lançar um novo edital para fazer mais uma concessão de transporte de passageiros.

- Exceção: inviabilidade técnica ou econômica: no caso de inviabilidade técnica ou econômica, que o Poder Público concedente deve justificar no edital da licitação, o serviço público poderá ser concedido ou permitido com caráter de exclusividade.

Ex.: na situação acima, digamos que a quantidade de pessoas que utilizará o transporte público de passageiros torne inviável economicamente que mais de uma empresa explore o serviço.

Lei Nacional n.º 8.987/1995

Art. 16. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica justificada no ato a que se refere o art. 5º desta Lei.

e) Contratação de terceiros: a empresa concessionária ou permissionária poderá contratar terceiros para implementar projetos e desenvolver atividades complementares ao serviço público concedido.

Isso não se confunde com subconcessão ou transferência da execução do próprio serviço público concedido ou permitido, que serão vistas a seguir.

f) Subconcessão ou subpermissão (parcial): subconcessão é a transferência parcial da execução do serviço público concedido ou permitido.

Para que a subconcessão ou subpermissão possa ocorrer, devem ser observados os seguintes requisitos:

- A possibilidade de subconcessão ou subpermissão deve estar prevista no contrato de concessão ou permissão;
- Mesmo estando prevista no contrato, deve ser expressamente autorizada pelo Ente Federado delegante;
- A subconcessão ou subpermissão somente pode ser parcial (nunca total: transferência);
- Deve ser realizada mediante licitação na modalidade concorrência, ou seja, haverá uma licitação para escolher a subconcessionária ou subpermissionária;
- A subconcessionária ou subpermissionária sub-rogar-se-á (assumirá) em todos os direitos e obrigações da concessionária ou permissionária, dentro dos limites da subconcessão ou subpermissão.

g) Transferência da concessão ou permissão (total): trata-se da entrega total do objeto da concessão ou permissão para outrem.

Para que a transferência possa ocorrer, devem ser observados os seguintes requisitos:

- Deve haver prévia anuência do Ente Federado delegante;
- O pretendente deve comprometer-se com todas as cláusulas do contrato em vigor.

→ Caducidade: se a concessionária ou permissionária transferir a concessão ou permissão sem a anuência do Ente Federado concedente, ocorrerá a caducidade da concessão ou permissão (veremos adiante).

h) Transferência do controle acionário: também se admite a ocorrência da transferência do controle acionário/societário da concessionária ou permissionária.

Aqui a mesma pessoa jurídica permanece como concessionária, mas há a alteração dos seus sócios (pessoas físicas).

Os requisitos para a transferência do controle acionário são os mesmos da transferência da própria concessão ou permissão, quais sejam:

- Deve haver prévia anuência do Ente Federado delegante;

- Os pretendentes (novos sócios) devem comprometer-se com todas as cláusulas do contrato em vigor.

→ Caducidade: a transferência do controle acionário sem a anuência do Ente Federado delegante também gera a caducidade da concessão ou permissão (veremos adiante).

i) Responsabilidade subsidiária do Ente Federado delegante: em caso de inadimplemento da concessionária ou permissionária perante terceiros (usuários, fornecedores...), a responsabilidade do Ente Federado delegante é apenas subsidiária.

Ou seja, o credor deve primeiro cobrar da delegatária (concessionária ou permissionária); somente se ela não tiver condições de satisfazer a obrigação, é que surge a responsabilidade do Poder Público concedente.

- Subsidiária ≠ solidária: como visto, na responsabilidade subsidiária a responsabilidade do terceiro (Ente Federado delegante) somente surge se o devedor principal (concessionária ou permissionária) não tiver meios de satisfazer a obrigação do credor.

Se se tratasse de responsabilidade solidária, o devedor principal (concessionária ou permissionária) e o terceiro (Ente Federado) responderiam em conjunto pela obrigação e o credor poderia exigir o cumprimento de um só ou de todos ao mesmo tempo (art. 264, CC).

Código Civil

Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.

Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

5.2. Prerrogativas do Poder Delegante

O Ente Federado, na condição de delegante do serviço público para a iniciativa privada mediante permissão ou concessão, possui uma série de prerrogativas, as quais passamos a estudar abaixo.

a) Alteração unilateral do contrato (art. 9º, §4º, Lei Nacional n.º 8.987/1995): o Ente Federado delegante possui a prerrogativa de alterar unilateralmente as cláusulas do contrato, ou seja, mesmo sem a anuência da permissionária ou concessionária.

Dito de outro modo, o Ente Federado pode impor à permissionária ou concessionária a alteração de cláusulas do contrato, sendo que a delegatária terá de aceitar a alteração.

Mas sempre deve ser assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, vale dizer, a permissionária ou concessionária tem o direito ao "recálculo" do valor que tem a receber.

Lei Nacional n.º 8.987/1995

Art. 9º A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato.

§ 4º Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração.

b) Extinção unilateral do contrato: o Ente Federado delegante também pode extinguir de maneira unilateral a permissão ou concessão antes do término do prazo estabelecido.

Ou seja, o Ente Federado pode romper o contrato com a permissionária ou concessionária, mesmo sem a anuência destas.

A extinção unilateral pode ocorrer em duas hipóteses, que serão estudadas em tópico próprio abaixo:

- *Encampação (interesse público);*
- *Caducidade (inadimplemento).*

c) Fiscalização: o Ente Federado delegante sempre tem a prerrogativa de inspecionar e fiscalizar o cumprimento do contrato para verificar se a permissionária ou concessionária está prestando o serviço público de maneira adequada.

d) Aplicação de penalidades: também tem a prerrogativa de aplicar penalidades contratuais e administrativas à permissionária ou concessionária, sem necessidade de ação judicial.

Ou seja, o Ente Federado pode aplicar penalidades de modo unilateral, sem necessidade de se socorrer do Poder Judiciário.

e) Intervenção: a intervenção é um procedimento acautelatório utilizado pelo Ente Federado delegante quando a permissionária ou concessionária está prestando de forma inadequada o serviço público que lhe foi concedido.

A intervenção obedece aos seguintes procedimentos:

- **Decreto de intervenção:** o Ente Federado delegante deve emitir um Decreto de intervenção, o qual, como todo ato público, deve ser publicado para que inicie sua vigência e validade (relembre-se que o Decreto é um ato privativo do chefe do Poder Executivo: não tem participação dos Poderes Legislativo e Judiciário).

Esse Decreto determinará a intervenção na permissionária ou concessionária, e deverá conter:

- **Designação do interventor:** o dirigente/gestor da permissionária ou concessionária é afastado da administração, sendo nomeado um interventor para gerir a delegatária durante o período da intervenção;
- **Prazo determinado:** a intervenção é sempre por prazo determinado, o qual deve constar do Decreto de intervenção; e
- **Objetivos e limites da medida:** por fim, a intervenção deve ser objetiva, para apurar situações específicas, as quais também devem constar do Decreto interventivo.

- **30 dias para instaurar processo administrativo:** decretada a intervenção (publicado o Decreto), a Administração Pública tem trinta dias para instaurar um processo administrativo de apuração de irregularidades.

Como em todo e qualquer processo administrativo (ou judicial), a permissionária ou concessionária terá direito a acompanhá-lo, com contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, CRFB/1988).

- 180 dias: o prazo máximo de duração do processo administrativo é de 180 dias.

Portanto, o prazo total da intervenção pode chegar a 210 dias = 30d para instaurar o processo administrativo + 180d de duração deste.

- Ausência de irregularidade: concluindo-se no processo administrativo pela ausência de irregularidade, o Poder Público deve:

- *Extinguir a intervenção;*
- *Prestar contas; e*
- *Devolver a administração da permissionária ou concessionária ao dirigente/gestor afastado.*

- Constatada irregularidade: agora, se for constatada alguma irregularidade, fica configurada a caducidade do contrato, ou seja, o inadimplemento da permissionária ou concessionária (os efeitos da caducidade serão estudados em tópico próprio abaixo).

Constituição Federal

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

5.3. Extinção da Permissão ou Concessão

A extinção da permissão ou da concessão pode ocorrer pelas hipóteses que seguem.

a) Término do prazo: essa é a forma ordinária de extinção da delegação do serviço público ao particular, que ocorre com a fluência do prazo de permissão ou concessão previsto no contrato administrativo.

Ou seja, finalizado o prazo previsto no contrato de permissão ou concessão, extingue-se automaticamente a delegação do serviço público.

→ Todas as demais cinco hipóteses de extinção, que veremos a seguir, são formas extraordinárias de extinção dos contratos administrativos de permissão ou concessão de serviços públicos, pois acontecem antes do término do prazo previsto no contrato.

b) Encampação (art. 37 da Lei Nacional n.º 8.987/1995): encampação é a retomada do serviço público pelo Ente Federado delegante antes do término do prazo da permissão ou concessão por motivo de interesse público.

Junto da caducidade (abaixo), é uma das hipóteses de extinção unilateral do contrato administrativo vistas no tópico anterior.

Para que a encampação possa ocorrer, devem estar presentes os requisitos abaixo.

- Motivo: deve haver alguma justificativa de interesse público para que o Ente Federado delegante possa realizar a encampação.

- Lei autorizativa específica: para a encampação, deve haver lei autorizativa específica, ou seja, o Ente Federado concedente (Poder Executivo) precisará que o Poder Legislativo concorde com a encampação.

- Indenização prévia: por fim, antes de efetivar-se a encampação, o delegatário (permissionário ou concessionário) deve ser indenizado em virtude do rompimento antecipado do contrato administrativo, cujo valor será apurado mediante levantamentos e avaliações.

Lei Nacional n.º 8.987/1995

Art. 37. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização, na forma do artigo anterior.

c) Caducidade (art. 38 da Lei Nacional n.º 8.987/1995): caducidade é sinônimo de inadimplemento do permissionário ou concessionário.

Ou seja, na caducidade, a extinção da permissão ou concessão ocorre em virtude de inexecução total ou parcial do contrato por parte do delegatário.

Junto da encampação (acima), é uma das hipóteses de extinção unilateral do contrato administrativo vistas no tópico anterior.

A caducidade possui as seguintes peculiaridades.

- Concessão de prazo para regularização: o Ente Federado delegante deve comunicar à permissionária ou concessionária quais são as falhas verificadas na prestação do serviço público, concedendo-lhe um prazo para regularizá-las, com vistas a evitar a caducidade da concessão.

- Processo administrativo: não sanadas as falhas, instaura-se um processo administrativo para apurar as inadimplências verificadas (inexecução total ou parcial).

Como em todo e qualquer processo administrativo (ou judicial), a delegatária terá direito a acompanhá-lo (contraditório) e a defender-se (ampla defesa), nos termos do inc. LV do art. 5º da CRFB/1988.

- Decreto de caducidade: se no processo administrativo foi apurada a inadimplência (total ou parcial) da permissionária ou concessionária, deve ser declarada a caducidade do contrato, o que ocorre por meio de um Decreto (ato privativo do chefe do Poder Executivo, sem a participação dos Poderes Legislativo ou Judiciário), que deve ser publicado para produzir efeitos (princípio da publicidade).

- Indenização posterior: assim como ocorre na encampação, aqui na caducidade a delegatária (permissionária ou concessionária) também terá direito à indenização.

Mas aqui a indenização pode ser paga depois da declaração de caducidade, ou seja, após a publicação do Decreto de caducidade – isso ocorre porque a caducidade ocorreu por culpa do delegatário.

Lei Nacional n.º 8.987/1995

Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, do art. 27, e as normas convencionadas entre as partes.

d) Rescisão: rescisão é a extinção judicial do contrato de permissão ou concessão, que se dá por iniciativa do delegatário (permissionário ou concessionário).